

## APUNTES COMPLEMENTARIOS PARA LA UNIDAD 5

\*Material confeccionado por la Dra Verónica Massachiodi en base al manual de derecho laboral de J. Grisolia

### Contrato de trabajo

El contrato de trabajo es el acuerdo por el cual una persona: *El trabajador* se compromete a prestar servicios para otra: *el empleador* a cambio de una remuneración (art. 21 de la LCT).

Como ya se ha dicho antes, hay contrato de trabajo independientemente de que las partes no le hayan dado ese nombre. Cualquiera sea la apariencia o disfraz que se le ponga, siempre será un contrato de trabajo. El contrato existe por el acuerdo de voluntades, aunque no esté plasmado en un papel. Hay contrato aunque no exista un papel que fije los deberes y derechos de las partes.

*Por eso es incorrecto decir “estoy por contrato”, para los que están contratados por un tiempo determinado. Todos los trabajadores están ligados al patrón por un contrato (escrito o no). Por eso la ley laboral se denomina: “Ley de Contrato de Trabajo”*

### La relación de dependencia

El contrato de trabajo presupone una situación de dependencia del empleado respecto del patrón. Esa relación de dependencia es un elemento fundamental en el contrato de trabajo. Se dice que el trabajador depende del patrón desde el punto de vista:

- *Económico*
- *Técnico*
- *Jurídico*

La *dependencia económica* se verifica por el hecho de que es el patrón el que aporta los recursos económicos para poner en marcha la empresa (inmueble, vehículos, máquinas, mercaderías, instalaciones). El empleado *depende* de esos recursos que aporta el empleador. Además el que gana o pierde con la explotación es el empresario, el que corre los riesgos.

La *dependencia técnica* está constituida por la autoridad que tiene el patrón para decidir cómo se ejecuta la tarea, como se organiza la producción, que técnicas emplear, etc. El trabajador queda obligado a someterse a esas decisiones, aunque no esté de acuerdo con ellas y aunque le parezca que esa forma de ejecutar la tarea no es la mejor.

La *dependencia jurídica* es el poder que tiene el empleador para obligar al empleado a cumplir con determinadas directivas: el horario, los descansos para comer o merendar, el otorgamiento de vacaciones, el uniforme que debe llevar el empleado, la forma de dirigirse a un superior, la frase que debe decir cuando atiende el teléfono, la forma de tramitar los avisos de enfermedad, etc. La máxima manifestación de este poder jurídico del empleador lo constituye la facultad que tiene el patrón para sancionar a sus empleados en caso de incumplimiento a sus obligaciones, imponiéndole suspensiones disciplinarias.

### Cuando no hay relación de dependencia: los autónomos

De lo que acabamos de decir se desprende que no hay contrato de trabajo cuando no hay relación de dependencia. El electricista o el plomero que tiene sus propias herramientas y hasta su propio vehículo y que atiende pedidos de trabajo de empresas o de particulares, no es dependiente, ya que trabaja por su cuenta. Tiene cierta autonomía económica, con su pequeño capital, su decisión de fijar el precio para sus servicios, y asumir la ganancia o pérdida de su emprendimiento. Además no recibe órdenes de las empresas para las cuales trabaja: fija sus horarios (viene cuando quiere, como se suele decir), y decide él mismo como hacer la tarea.

No es empleado, porque no hay relación de dependencia. Algunos trabajadores prestan servicios en situaciones donde la dependencia no queda claramente configurada: los fleteros, remiseros, o motoqueros que trabajan con vehículos propios en forma habitual para determinada empresa.; profesionales de la salud que con cierta libertad ejercen su trabajo en sanatorios.

#### El trabajador es siempre una persona física

• *Un hombre o una mujer que presta sus servicios en forma personal, sin que pueda delegar en otro la prestación de sus tareas.*

#### En cambio el empleador puede ser:

- *Una persona física*
- *Varias personas que utilizan los servicios de un mismo trabajador (por ejemplo, varios médicos que comparten una misma secretaria)*
- *Una sociedad comercial (SRL, SA, u otras)*
- *Una asociación o entidad civil (un club, una fundación, un sindicato)*

#### Duración del contrato de trabajo: tiempo indeterminado

El contrato de trabajo, está pensado como un vínculo duradero y estable, es decir, una relación *destinada a durar*, no algo transitorio o accidental. Por eso es que el contrato de trabajo, en su forma “normal”, es de tiempo *indeterminado*. Durará hasta que se produzca alguna de las circunstancias previstas en la ley como motivo de extinción:

- *El despido dispuesto por el patrón, con o sin justa causa.*
- *El despido indirecto decidido por el trabajador*
- *La renuncia*
- *El acuerdo entre empleador y trabajador*
- *La jubilación*
- *La incapacidad del trabajador*
- *La muerte del trabajador*

#### Al trabajador le interesa el empleo estable

Esta idea de permanencia es de interés para el trabajador, porque le garantiza un crecimiento personal y profesional dentro de la empresa. Como todos sabemos de este modo el trabajador se realiza como persona y se asegura un ingreso, que presumiblemente irá mejorando a lo largo del tiempo, afianzando su proyecto de vida personal y familiar.

#### Al empresario también le tendría que interesar el empleo duradero

El empleo estable es también (o debería ser) un objetivo empresarial. La permanencia del trabajador en la empresa, su seguridad de que habrá de tener un empleo duradero y con condiciones de trabajo crecientemente más ventajosas, garantiza la lealtad del personal, su contracción al trabajo y la voluntad de capacitarse y superarse por parte del trabajador. El objetivo de mantenimiento de empleos estables y duraderos está contenido en el artículo 14 Bis de la Constitución, que además de asegurar condiciones dignas y equitativas de labor, al garantizarle al trabajador “*protección contra el despido arbitrario*”, está adhiriendo a la idea de preservar los contratos de trabajo. Más adelante veremos cómo se hace efectiva (y hasta dónde es efectiva) esa protección contra el despido arbitrario.

## El principio de indeterminación del plazo

La voluntad política de que el contrato de trabajo dure hasta el momento de la jubilación está plasmada en el artículo 10 de la LCT cuando establece la figura del contrato por tiempo indeterminado como regla general para la duración del contrato de trabajo. El artículo 10 define al contrato de tiempo determinado: *“El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios...”*. La relación laboral está pensada para durar hasta la jubilación, aunque en el camino pueden ocurrir otras cosas, como lo prevé la segunda parte de la frase: *...salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley” (renuncia, despido, muerte, incapacidad)*. Se llama contrato de trabajo por tiempo indeterminado porque no tiene un tiempo de duración previsto de antemano.

Está pensado para durar hasta la jubilación, aunque en el camino algo puede pasar. Así como la fórmula del amor matrimonial “hasta que la muerte nos separe” no siempre se cumple, y la gente se separa antes de morirse, en el contrato de trabajo también ocurre que se termine antes de que la jubilación “nos separe”.

## El período de prueba: “estoy a prueba”

Durante los tres primeros meses de la relación laboral, el contrato de trabajo se considera en período de prueba. Esto significa que durante ese tiempo, el empleador puede, supuestamente, evaluar las condiciones y aptitudes de su empleado, pudiendo despedirlo sin pagarle indemnización con un preaviso de apenas quince días. (art. 92 LCT).

## **Las excepciones a la regla del plazo indeterminado:**

### Los que “están por contrato”

Hay casos en que una empresa puede necesitar trabajadores para cubrir situaciones excepcionales y transitorias:

- *Para reemplazar personal que se encuentra de vacaciones, o de licencia por enfermedad o maternidad.*
- *Para cumplir tareas puntuales de duración ya prevista (promotoras para un evento o exposición).*
- *Un pedido excepcional de un cliente que exige más personal para atender esa demanda puntual de trabajo.*

En esos casos, la ley permite contratar personal por un tiempo determinado, de lo que debe dejarse constancia con un contrato escrito (art. 90 LCT). Es por eso que a estos trabajadores se los llama incorrectamente *“trabajadores por contrato”* o *“que están por contrato”*, porque firman un contrato escrito. Pero todos los trabajadores en relación de dependencia tienen “un contrato” aunque no haya papel firmado, como dijimos en el capítulo anterior.

## Contrato de trabajo de temporada

Así como la regla en cuanto a duración del contrato de trabajo es la de permanencia o continuidad, también la prestación de servicios por parte del trabajador es, como regla general, de carácter continuado. Sin embargo, hay situaciones, en las que la naturaleza misma de la tarea autoriza una prestación de carácter discontinuo. Es el caso de actividades que sólo trabajan en determinada época del año (los hoteles ubicados en lugares de veraneo, el personal que trabaja en la pileta de un club), o que reducen considerablemente su actividad en determinadas épocas del año (las fábricas de helados). Estos casos llamados empleos de

temporada (art. 96 LCT) el trabajador es contratado por tiempo indeterminado pero su desempeño es discontinuo, ya que presta servicios sólo en determinada época del año, y permanece inactivo (y sin cobrar remuneración) en los períodos de receso. El trabajador vuelve a reintegrarse al trabajo al comenzar la nueva temporada, y la situación se mantiene así a lo largo del tiempo, con duración indeterminada.

### Las empresas de servicios eventuales

La ley permite que en determinadas circunstancias, los empresarios puedan recurrir a contratar trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, también llamadas “agencias”. No cualquier trabajo puede hacerse por agencia. La ley sólo autoriza a incorporar trabajadores mediante este tipo de intermediarias en situaciones excepcionales, tales como:

- *Ante la ausencia de un trabajador permanente, por licencia por enfermedad, maternidad, o vacaciones.*
- *Demanda excepcional de trabajo de carácter transitorio (un pedido de magnitud fuera de lo común)*
- *Participación en congresos, conferencias, exposiciones (la empresa quiere montar un stand en un congreso o en la Rural)*
- *Trabajos de mantenimiento o reparación urgentes que no se pueden realizar con el personal de planta de la empresa (arreglar máquinas que se han quemado o accidentado).*

### Remuneración

A cambio de la prestación de sus servicios, el trabajador recibe como principal contraprestación su remuneración (jornal, sueldo o comisiones) por su desempeño (al final de cuentas, para eso se trabaja). El sueldo es una consecuencia lógica de la prestación de servicios, al punto que, para la ley, el trabajo no se presume gratuito (art.115 LCT).

### Me tienen que pagar aunque no haya trabajo

El patrón está obligado a pagar el sueldo aunque el trabajador permanezca inactivo por falta de demanda (caso de un negocio durante el tiempo en que no entra nadie a comprar, una guardia médica o de mantenimiento en la que no hay llamados). El sueldo se debe por el hecho de que el trabajador está a disposición del empleador, haya o no trabajo para hacer.

### ¿Quién fija el sueldo?

El sueldo del trabajador es el que está fijado en el convenio colectivo de trabajo, o, el que hayan convenido las partes (siempre que sea más alto que el del convenio). Además, nunca puede ser inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil.

### Formas de determinar el sueldo

El sueldo puede calcularse de varias maneras (art. 104 LCT):

- *Por tiempo trabajado (hora, día o mes), que es la forma más común.*
- *También por rendimiento en el trabajo, cuando se calcula en función de:*
  - *Las ventas en el caso de trabajadores a comisión.*
  - *Por unidad de obra (por prenda confeccionada, por metro cuadrado de azulejo colocado, por cada entrega que hace un repartidor). En estos casos, el sueldo no puede ser inferior al que le hubiera correspondido cobrar al trabajador en función del pago por hora o por mes.*
- *Porcentaje de las ganancias de cada negocio que se concreta o de las utilidades de la empresa.*
- *Premios en cualquiera de sus formas o modalidades.*

- *Viáticos cuando se pagan sin obligación de rendir cuentas (tanto por día o por kilómetro), y no cuando hay que presentar facturas de nafta y restaurant o pasajes (art. 106 LCT).*

En casos excepcionales, cuando no exista un sueldo fijado por convenio colectivo y las partes no hubieran pactado nada al respecto, los jueces tienen facultades para determinar la remuneración (art. 114 LCT).

### Como se paga el sueldo

El salario debe ser satisfecho en dinero, pero también puede completarse con otras prestaciones que vienen a formar parte de la remuneración:

- *Si al trabajador se le da una vivienda.*
- *Cuando se le entrega un vehículo para uso particular.*
- *En los casos que recibe otras prestaciones en beneficio suyo y de su familia.*
- *También cuando al trabajador se le brinda la oportunidad de hacer trabajos por su cuenta y obtener una ganancia.*

### Lo que no integra la remuneración (art. 103 Bis LCT)

Hay ciertas prestaciones que no forman parte de la remuneración. Entre ellas se cuenta lo que el trabajador recibe como complemento de su trabajo o para mejorar su formación:

- *Los servicios de comedor de la empresa.*
- *La provisión de ropa de trabajo.*
- *Lo pagos que la empresa autorice para cursos de formación profesional o capacitación.*

En otros casos, son beneficios de asistencia social que la empresa quiere brindarle al empleado o sus familiares:

- *El pago de determinada cobertura médica.*
- *Los gastos de guardería de niños.*
- *La entrega de útiles escolares o guardapolvos.*
- *El pago de gastos de sepelio del trabajador o familiares.*

Entre los conceptos que no integran la remuneración se encontraban los llamados vales alimentarios o *tickets canasta*, que pasaron a ser una forma de dar aumentos sin aumentar el sueldo, o de pagar sueldos que no eran sueldos. Hoy esos vales son considerados remuneración.

### **Si me pagan plata por mi trabajo ¿es remuneración?**

#### ¿Y la remuneración no remunerativa??

Aunque parezca mentira, así como hay café sin cafeína, hay remuneración no remunerativa. Es decir algo que se paga por el trabajo prestado (y que es parte de la remuneración), pero que en algunos acuerdos o convenios se establece que *no son remunerativas*, es sueldo para gastarlo, pero no se considera sueldo para:

- *Hacer aportes a la seguridad social.*
- *Calcularlo para indemnizaciones por despido o accidente.*
- *Incorporarlo para determinar aguinaldo, vacaciones y adicionales.*

Es una situación híbrida e irregular que se viene tolerando en algunos convenios colectivos de trabajo para salir del paso y otorgar aumentos, aunque en general se exige que esos pagos no remunerativos tengan

una duración limitada en el tiempo (por eso los convenios los fijan por unos meses, y después los pasan al sueldo).

### ¿Cuándo se paga la remuneración?

- *A los trabajadores mensualizados hay que liquidarles a fin de mes.*
- *A los que cobra por jornal o por hora, se les debe liquidar quincena.*
- *El plazo para pagar es de cuatro días hábiles (arts. 127 y 128 LCT).*

### ¿Cómo se paga?

*La ley obliga a pagar el sueldo en dinero, aunque por razones prácticas y de seguridad también se admite el pago mediante cheques. En la actualidad se va imponiendo la exigencia de abonar las remuneraciones mediante depósito en una caja de ahorros a nombre del trabajador, lo que da transparencia al pago y seguridad en cuanto a monto y fecha.*

### Recibos de sueldo

*El empleador debe confeccionar un recibo de sueldo donde consten los datos personales del trabajador como categoría y fecha de ingreso y los conceptos que integran el pago y entregar al trabajador un duplicado del mismo.*

### El aguinaldo

El aguinaldo (llamado en la ley Sueldo anual complementario, y abreviado SAC), es un sueldo más que se paga en el año. Aunque existía en algunas pocas actividades, fue una de las tantas medidas que implementó el General Perón cuando era todavía Secretario de Trabajo y Previsión, allá por 1944. Al principio era un sueldo más que se abonaba a fin de año, para pagar los gastos de las fiestas, y para poder salir de vacaciones. Con el tiempo, para no hacerlo tan pesado para las empresas, se lo dividió en dos mitades, que se pagan a fin de junio y a fin de diciembre de cada año.

### **Embargo de sueldos**

#### ¿Qué parte del sueldo me pueden embargar?

Casi todo el mundo piensa que sólo puede embargarse hasta el 20% de la remuneración del trabajador. Sin embargo, no es exactamente así, ya que en los hechos se puede embargar bastante menos.

Sucede que lo que gana un trabajador hasta alcanzar el importe del valor de un salario mínimo vital y móvil, es inembargable. De lo que exceda el valor de un salario mínimo vital y móvil, sólo se puede embargar el 10%, y en lo que supera dos veces el salario mínimo se puede embargar el 20%.

### Trabajo de mujeres. Protección del matrimonio y maternidad.

Una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores fue la de brindar una protección especial a la mujer trabajadora. Pero al mismo tiempo, también las mujeres reclaman una real igualdad de remuneraciones, de trato y de oportunidades respecto de los varones.

### Igualdad salarial y de trato

La primera regla en materia de trabajo de mujeres es la de asegurarles igualdad salarial respecto de los hombres (art. 172 LCT), prohibiendo también las discriminaciones por causa del estado civil de la mujer. *Pero...* Sin embargo, en la práctica en muchas empresas, por no decir en todas, las mujeres suelen ocupar cargos de menor jerarquía que los hombres, frecuentemente son postergadas en los ascensos, cuando no reciben un trato menos considerado que los varones.

#### Prohibición de determinadas tareas a las mujeres

La LCT prohíbe ocupar a mujeres en tareas caracterizadas como penosas, peligrosas o insalubres.

#### Una disposición abandonada: el descanso al mediodía

Una norma caída en desuso prevé que las mujeres deben tener un descanso al mediodía si trabajan en horas de la mañana y en horas de la tarde. En la actualidad esa disposición ha perdido toda vigencia, porque en los hechos es frecuente que las mujeres presten servicios en jornada continua, incluso en su propio beneficio.

#### Protección de la maternidad

Sin duda el aspecto más relevante referido al trabajo de mujeres lo constituye la protección de la maternidad.

#### La licencia por maternidad

La LCT denomina “prohibición de trabajar” al período anterior y posterior al parto, en que se reconoce un descanso obligatorio que conocemos con el nombre de “licencia por maternidad”. Es un período de 45 días antes de la fecha prevista para el parto y otros 45 días posteriores al nacimiento. En total son 90 días, a contar desde que la trabajadora dejó de prestar servicios, aunque el nacimiento se haya anticipado a la fecha prevista. Durante el tiempo de inasistencia, el empleador no abona la remuneración de la trabajadora, ya que el pago de esos salarios queda a cargo del sistema de asignaciones familiares.

#### Situaciones que pueden presentarse al concluir la licencia por maternidad

Al finalizar la licencia por maternidad, se le brindan a la trabajadora varias opciones:

- *Reintegrarse a trabajar normalmente.*
- *Retirarse del empleo, percibiendo una indemnización equivalente al 25% de la indemnización por despido.*
- *Solicitar licencia sin goce de sueldo por un lapso de entre tres y seis meses, conocido como estado de excedencia. Esta opción, poco utilizada por los trabajadores tiene una complicación: Si al tiempo de finalizada esa licencia el empleador no puede reintegrarla a su trabajo porque no tiene vacantes para ella, se opera la ruptura del contrato de trabajo, con el pago de una indemnización del 25% de la que corresponde a un despido.*

#### Descansos por lactancia

La LCT establece una reducción de la jornada de trabajo consistente en dos períodos de media hora cada uno para permitirle amamantar a su hijo.

#### Indemnizaciones por despido agravado por causa de embarazo, maternidad o matrimonio.

La LCT procura proteger a la mujer en las contingencias de embarazo, maternidad y también en caso de matrimonio. Sabiendo que los patrones intentan desprenderse de las empleadas embarazadas o que tienen

hijos pequeños, y también las que se casan (presumiendo que después de su casamiento habrán de buscar ser madres), se prevé una indemnización reforzada en los casos en que el despido se produzca:

- *Dentro de los 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha del parto.*
- *Dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores a la fecha del matrimonio.*

En estos casos, y siempre que la trabajadora haya notificado el embarazo, nacimiento o matrimonio al empleador, de producirse el despido a las indemnizaciones ya previstas en la ley se le adiciona el equivalente a un año de remuneraciones (13 sueldos, es decir, los 12 meses más el aguinaldo). Esta protección también puede hacerse extensiva al trabajador varón si de las circunstancias del despido surge que la decisión fue adoptada como consecuencia del enlace.

### Trabajo de menores

El trabajo infantil se encuentra prohibido en nuestro país, conforme los criterios sustentados por la OIT. Recientemente se ha fijado como edad mínima para el trabajo, la de 16 años (antes era 14) La única excepción la constituye el caso de menores que, con más de 14 años de edad, trabajan en empresas de sus padres. En estos casos no pueden trabajar más de 3 horas diarias o 15 semanales. *El trabajo de menores de entre 16 y 18 años está sujeto a algunas restricciones:*

- *No pueden trabajar en tareas nocturnas.*
- *No pueden trabajar en tareas peligrosas, penosas o insalubres.*

### Enfermedades y accidentes inculpables

Como una consecuencia de la condición de subordinación del trabajador respecto del empleador, la ley establece que el patrón tiene que hacerse cargo de pagarle salarios y conservar el empleo al trabajador en caso de enfermedad o accidente y por un tiempo limitado. Se trata de enfermedades o accidentes que no guardan ninguna relación con el trabajo, ya que las provocadas por el trabajo caen bajo la responsabilidad del empleador, y tienen un régimen legal especial.

*El plazo de licencia paga por enfermedad varía según la antigüedad y cargas de familia del trabajador:*

- *Con menos de 5 años de antigüedad en el empleo, el máximo de licencia es de 3 meses que se duplica a 6 meses si el trabajador tiene cargas de familia.*
- *Con más de 5 años de antigüedad el máximo pasa a ser de 6 meses, y de un año para el que tiene cargas de familia.*

Estos plazos se cuentan por cada enfermedad que padezca el trabajador. Una enfermedad distinta dará derecho a otra licencia por los mismos plazos. En caso de recaída en una enfermedad crónica para que el trabajador tenga derecho nuevamente a estos plazos de licencia paga deben haber transcurrido dos años.

### Aviso y control de la enfermedad

La ley prevé que el trabajador tiene la obligación de avisar a su patrón la imposibilidad de concurrir a trabajar.

### Reserva del puesto (o año de espera)

Si vencidos los plazos legales de 3, 6 o 12 meses, según el caso, el trabajador no está en condiciones de reintegrarse, la ley contempla que se le conserve el empleo al trabajador por un lapso de un año, conocido



como “año de espera”, a la espera justamente de que se cure. Claro que en este año de espera no se abonan salarios...

### ¿Y si se cura?, ¿O si no se cura?

En ese tiempo de espera pueden pasar varias cosas:

- *Que el trabajador se cure por completo y pueda volver a trabajar. Y si no lo reincorporan, se considerará despedido.*
- *Que se le dé el alta, pero sin que pueda volver al trabajo que hacía antes. En ese caso, el trabajador podría reincorporarse a tareas adecuadas a su capacidad.*
- *Si en el establecimiento hay tareas adecuadas, el empleador tiene la obligación de reincorporarlo. Y si no lo reincorpora, el trabajador se considerará despedido.*
- *Si no hay tareas adecuadas, se opera la ruptura del contrato de trabajo, y el empleador debe pagar el equivalente a la mitad de una indemnización por despido.*
- *Que el trabajador quede incapacitado en forma total para el trabajo, en cuyo caso, se produce la ruptura del contrato de trabajo con pago de una indemnización equivalente a la de un despido.*

Este aviso debe darse lo más pronto posible. La ley no prevé la forma de dar aviso de la enfermedad. Es una situación que depende de las costumbres de la empresa. La forma más usual es por teléfono, aunque en situaciones de conflicto o en las que se presume mala fe es aconsejable enviar un telegrama para que quede constancia del aviso. También puede cursarse una comunicación por e-mail, que es gratis, funciona a toda hora y queda registrada.

### El control médico

La ley le da derecho al empleador a controlar la enfermedad que padece el trabajador, a través de un médico de su confianza.

### **Cuando los médicos no se ponen de acuerdo...**

Suele pasar que el médico de control de la patronal no justifique las inasistencias que avala el médico del trabajador.

### Lo que se puede hacer

En estos casos, el trabajador (también el empleador), pueden solicitar la intervención de una oficina de reconocimientos médicos que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia, a fin de obtener una opinión de un tercero. Si bien ninguna de las dos partes está obligada a concurrir a ese control médico, la negativa a concurrir puede configurar una presunción en contra del que resistió la citación. En el caso del trabajador, es aconsejable que intime a su empleador a concurrir a través de un representante médico, dejando constancia que la negativa será considerada una presunción en su contra.

### **Jornada de trabajo**

La jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador tiene que estar a disposición del empleador, y que no puede utilizar en beneficio propio (art. 196 LCT). *Así, los empleados de un negocio, los mozos de un bar, o los que atienden al público en una oficina, mientras esperan que vengan clientes, aunque no hagan nada se considera que están trabajando. No se pueden ir de paseo o a dormir la siesta, se tienen que quedar ahí.* Cuando no existían normas protectorias del trabajo, la jornada de trabajo la imponía el empleador con la lógica

de máximo rendimiento con el mínimo costo. Así es como se imponían jornadas de 14 y más horas, y de ahí que la reducción de la jornada de trabajo fue una de las primeras reivindicaciones obreras.

### La jornada normal de 8 horas

La jornada de trabajo en la Argentina, en situaciones normales, está fijada en 8 horas diarias y 48 horas semanales. (Ley de Contrato de Trabajo y ley 11.544).

### Las jornadas reducidas por convenio colectivo de trabajo.

Muchos convenios colectivos de trabajo fijan jornadas más cortas que las 8 horas diarias y 48 semanales. Así, hay actividades que tienen un límite de 44 horas semanales, usualmente distribuidas a razón de 8 horas de lunes a viernes, y 4 horas el sábado por la mañana.

### La jornada nocturna de 7 horas

Se llama trabajo nocturno al que se desarrolla entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Como trabajar de noche es más cansador que trabajar de día, la ley limita la jornada nocturna a 7 horas en lugar de 8.

### La jornada insalubre de 6 horas

Hay trabajos que son nocivos para la salud, o que implican riesgos especiales (trabajo en una mina, con sustancias tóxicas, tareas que generan mucha tensión). En esos casos la ley fija una jornada reducida de 6 horas diarias y 36 semanales.

### Trabajo en turnos rotativos

En ciertas actividades en que el trabajo no puede interrumpirse nunca (guardias de salud o de servicios públicos, fábricas de producción continua), el trabajo se realiza “por equipos” o grupos de trabajadores que van rotando. De modo que uno trabaja por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, y otro descansa. Luego de una semana, el ciclo vuelve a reiniciarse, rotando los de la mañana con los tarde y así, sucesivamente.

### El patrón fija los horarios de trabajo

Como una facultad propia del poder de dirección del patrón y de la dependencia jurídica del trabajador, el que fija el horario de trabajo es el empleador.

### Los que no tiene horario: gerentes y personal superior

La ley de jornada reconoce excepciones. Directores y gerentes, es decir los jerárquicos de la empresa, están a disposición de la patronal con mayor amplitud. Tienen más libertad horaria, y no pueden alegar que se van a su casa porque terminó su jornada.

### En caso de urgencia hay que quedarse en el trabajo

Como una lógica consecuencia del deber de colaboración impuesto al trabajador, la ley establece que en situaciones de accidentes, o en casos de urgencia, los trabajadores tienen la obligación de continuar prestando servicios, y no pueden alegar que se retiran a su casa porque “es la hora”.

### Trabajo a tiempo parcial

Hay situaciones en las que los trabajadores prestan servicios en jornada reducida. Es lo que se conoce como “trabajo a tiempo parcial”: personas que trabajan, por ejemplo, cuatro o cinco horas diarias en lugar de las ocho horas normales. En estos casos, la ley dispone que si el trabajador se desempeña con una carga horaria inferior en 2/3 a la jornada normal (seis horas en el caso de jornada de ocho horas), su remuneración deberá ser proporcional a la fijada para jornada completa. En cambio, si el desempeño es superior a esos 2/3, el sueldo deberá ser el mismo que el que trabaja jornada completa.

### **Horas extras**

Puede ocurrir que la jornada de trabajo se extienda más allá del límite legal de ocho horas. En ese caso, esas horas trabajadas de más (conocidas como horas extras), se deben pagar con un recargo del 50% del valor normal si son prestadas en días comunes, o del 100% si se trata de días destinados al descanso (sábados y domingos, o días francos para los trabajadores que descansan otro día de la semana).

### Límite de las horas extras

En la actualidad existe una limitación respecto de la cantidad de horas extras que pueden realizar los trabajadores. Ese límite es de 3 horas diarias, 30 horas al mes y 200 en el año. En realidad, el límite se cumple poco y nada. Los empresarios, cuando lo necesitan, exceden ese límite en función de sus intereses. Muchos trabajadores aceptan porque necesitan aumentar sus ingresos, y los que no quieren trabajar horas extras no se animan a enfrentar al empleador diciéndole que no por temor a las represalias.

### Carácter voluntario de las horas extras

El trabajador no está obligado a hacer horas extras salvo situaciones excepcionales como accidentes, situaciones de emergencia, o necesidades imperiosas de la empresa. Sin embargo, en las actuales circunstancias, todos los trabajadores quieren hacer horas extras porque así redondean unos pesos más a fin de mes.

### El abuso patronal con las horas extras

La cuestión de las horas extras se prestan también a abusos por parte de la patronal. En muchas empresas, las horas extras se hacen “*en negro*”. Eso permite muchas veces pagar el trabajo sin los correspondientes recargos legales. En muchas otras, directamente las horas extras no se pagan, el empleador abusa de esta situación sabiendo que los trabajadores se van a someter a las imposiciones del patrón, y que además, difícilmente puedan ganar un juicio por horas extras.

### ¿Se acabó la conquista social de las 8 horas de trabajo?

La jornada de 8 horas, una conquista sagrada para los trabajadores, está cada día más en baja. En la actualidad, dada la incertidumbre de los trabajadores respecto de su futuro, y sueldos que no siempre alcanzan, todos tratan de mejorar sus ingresos con horas extras. En otros casos, los patrones obligan a los empleados a hacer horas extras, que se pagan a veces sí u otras más o menos y otras no. Conclusión que, por una cosa o por otra, al final la conquista de las ocho horas está medio perdida.

### Descanso semanal

Como parte de las reivindicaciones de los trabajadores a la reducción de jornada se instala el concepto de descanso semanal. Fue así como en nuestro país, precisamente, la primera ley laboral que se sancionó fue la de descanso dominical. Posteriormente se amplió el descanso semanal a instituirse el llamado “sábado inglés” (por el país de origen de la conquista), es decir el descanso en la tarde del día sábado. De ahí que en la actualidad el artículo 204 de la LCT dispone la *prohibición* de trabajar desde las 13 del sábado a las 24 horas

del día domingo. Sin embargo, en la práctica, cada día son más las excepciones a esa regla. Si bien en muchos casos hay actividades que no pueden dejar de operar en días sábados y domingos (emergencias, servicios públicos, procesos industriales continuos, espectáculos o esparcimiento), también hay cada vez más actividades comerciales y de servicios que se han ido aceptando como excepción a esta prohibición (los supermercados, shoppings y centros comerciales son un buen ejemplo de esto). Los trabajadores han terminado por aceptar este régimen de trabajo por necesidad, y por falta de fuerza para oponerse a esta imposición patronal. *Tantos años luchando para descansar los domingos y miren dónde fuimos a parar.*

### Descansos compensatorios

En todos los casos en que el trabajador, por cualquier causa trabaje en días sábados y domingos, el patrón tiene la obligación de otorgarle un descanso compensatorio en la semana (algo así como correr el sábado y domingo en el almanaque y en lugar de descansar el fin de semana, descansar el lunes, el martes o el jueves).

### **Vacaciones**

La ley prevé un descanso anual pago para el trabajador proporcional al tiempo de antigüedad en el empleo:

- *14 días si la antigüedad es menor de 5 años.*
- *21 días si tiene más de 5 años pero menos de 10 de antigüedad.*
- *28 días si la antigüedad es de más de 10 años, y menos de 20.*
- *35 días corridos cuando la antigüedad supera los 20 años.*

Algunas aclaraciones sobre cómo se otorgan esas vacaciones:

- *Se cuentan días corridos, no días hábiles, salvo algunos convenios que así lo disponen.*
- *La antigüedad se computa al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones.*
- *Para tener derecho a gozar la vacación completa el trabajador debe haber prestado servicios al menos la mitad de los días del año, en caso de que no sea así, se otorgan en forma proporcional, a razón de 1 día de vacaciones por cada 20 trabajados.*
- *Las vacaciones deben empezar un día lunes o el siguiente hábil si el lunes resultase feriado.*
- *Las vacaciones se deben otorgar entre el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año y hay que comunicarlas con no menos de 45 días de anticipación.*
- *El pago de las vacaciones se debe efectuar al comienzo de las mismas, y se calcula dividiendo el importe del sueldo mensual por 25 y multiplicándolo por la cantidad de días que debe gozar el trabajador. Si se trata de trabajadores jornalizados se pagan la misma cantidad de jornales que días de vacaciones.*

### Licencias especiales

Además de la licencia anual, más conocida como vacaciones, la ley también prevé algunas otras licencias por determinadas situaciones personales del trabajador. Son las llamadas licencias especiales:

- *2 días por nacimiento de hijo.*
- *10 días por matrimonio.*
- *3 días por fallecimiento de cónyuge o pareja conviviente, hijos, o padres.*
- *1 día por fallecimiento de hermano.*
- *2 días de licencia para rendir examen secundario o universitario, con un máximo de 10 días al año.*

Los convenios colectivos muchas veces amplían estas licencias, a veces consignando otras causas, o ampliando los días que fija la ley.

## **Extinción del contrato de trabajo**

Como ya hemos visto el contrato de trabajo está pensado como un vínculo duradero de tiempo indeterminado. Aunque la ley tiene la intención de que el contrato de trabajo dure hasta la jubilación del trabajador, también se prevén distintas causas por las cuales el contrato puede extinguirse antes de que el trabajador esté en condiciones de jubilarse. El contrato de trabajo puede concluir, entonces, por varias razones:

- *Renuncia por decisión del trabajador.*
- *Incapacidad del trabajador para continuar prestando servicios (habitualmente cuando se jubila por invalidez).*
- *Fallecimiento del trabajador.*
- *Jubilación ordinaria del trabajador en condiciones de edad y años de servicio para retirarse.*

### También por despido dispuesto por el patrón

Puede suceder que el contrato de trabajo termine por decisión del patrón, esto es cuando éste dispone el despido del trabajador.

### O despido indirecto dispuesto por el trabajador

A veces ese despido en lugar de ser decidido por el empleador, es el resultado de una decisión del trabajador que pone fin al contrato culpando al patrón de esta situación. Es lo que se conoce como despido indirecto.

### Protección contra el despido arbitrario

La Constitución Nacional en el artículo 14 Bis establece la garantía de “*protección contra el despido arbitrario*”, es decir contra la decisión del patrón de despedir a su empleado sin una causa justificada.

### ¿Cómo protege la ley contra el despido?

La Ley de Contrato de Trabajo ha reglamentado esa protección estableciendo que en caso de despido sin justa causa, el patrón deberá abonar una indemnización.

Los trabajadores del sector público tienen una garantía de estabilidad en el empleo consagrada por el artículo 14 Bis (“*estabilidad del empleado público*”) mientras que los demás trabajadores sólo tienen derecho a lo que la constitución denomina “*protección contra el despido arbitrario*”.

Es decir que: mientras los empleados públicos no pueden ser despedidos si no media una justa causa y previo sumario administrativo, a los trabajadores privados se los puede despedir haya o no justa causa, y si no hay causa legítima, sólo tienen derecho a una indemnización por despido.

## **Despido sin causa**

La ley de contrato de trabajo establece dos obligaciones para el empleador que quiere despedir sin causa (sin explicar los motivos) a un empleado:

- *Preavisar (es decir avisarle con anticipación que lo va a despedir), con una anticipación de:*
  - *Un mes como mínimo si el trabajador tiene una antigüedad de menos de cinco años*
  - *Dos meses si tiene una antigüedad de más cinco años. (art. 231 LCT). El patrón puede optar por no otorgar el preaviso, y abonar lo que corresponda por ese mes o dos meses directamente con la indemnización por despido. Hoy día la inmensa mayoría de los despidos se implementan de ese modo.*
- *Pagar una indemnización por antigüedad de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses (es decir que si el trabajador tiene cinco años y cuatro meses de antigüedad se calcula en seis meses de sueldo).*

Más adelante veremos cómo se calcula esta indemnización

Si no me pagan... ¡a juicio!

Aunque parezca mentira, hay patrones que despiden sin causa, y después no quieren pagar la indemnización. O le ofrecen menos plata de la que le corresponde, o quieren pagarle en cómodas cuotas. Otras veces calculan mal la indemnización para pagar menos. En todos esos casos el trabajador no tendrá más remedio que iniciar un juicio, situación muy difícil, porque se encontrará sin trabajo y sin plata, lo que muchas veces lo obliga a ceder a las presiones del empleador y aceptar cobrar en cuotas o hacer rebajas. Para tratar de frenar esta situación se dictó una ley (complementaria de la Ley de Contrato de Trabajo), que impone un recargo del 50% para los empleadores que obligan al trabajador a iniciar juicio para cobrar la indemnización que les corresponde, o la diferencia, si se les hubiera pagado de menos (art. 2 ley 25323). En la provincia de Santa Fe se ha implementado un procedimiento abreviado, una especie de “juicio express” para este tipo de situaciones.

### Despido con causa

La ley autoriza al empleador a despedir a un trabajador si considera que hay una situación de incumplimiento por parte del trabajador de tal gravedad que impide continuar la relación laboral (art. 242 LCT). No hay un listado de los casos que justifican el despido de un trabajador, porque sería una enumeración interminable y siempre incompleta. Pero podemos dar algunos de los ejemplos más comunes:

#### *Inconducta grave del trabajador:*

- *Un empleado que agrede al capataz o a otro compañero.*
- *Un dependiente que destruye intencionalmente máquinas o instalaciones de la empresa.*
- *El robo de mercaderías o herramientas.*
- *Trabajador que agrede a un cliente del establecimiento.*
- *Un jefe que acosa sexualmente a la secretaria.*
- *Trabajador que se instala por su cuenta en una actividad que compite con la de la empresa en la cual presta servicios.*

En otros casos, ciertas conductas del trabajador que no son por si solas causas de despido pueden constituir un buen motivo si se repiten:

- *Incumplimiento de obligaciones por parte del trabajador.*
- *Provocar daño en las máquinas o instalaciones por descuido.*
- *No acatar órdenes de sus superiores.*
- *Faltar seguido.*
- *Llegar tarde en forma reiterada.*
- *Tener una conducta indisciplinada que se repite pese a las sanciones o advertencias anteriores.*

Estos incumplimientos normalmente no son tan graves como para que un solo hecho de lugar al despido con causa. Tienen que ser conductas que se van repitiendo (caso del trabajador que falta a cada rato sin motivo) y requieren que el empleador, con anterioridad haya ejercido hacia el trabajador su poder disciplinario, esto es que haya habido advertencias, llamados de atención y suspensiones anteriores por la misma causa, para que su reiteración adquiera la suficiente gravedad como para despedir.

## **Abandono de trabajo**

Si el trabajador abandona el trabajo, es decir desaparece y deja de concurrir a trabajar, sin duda incurre en causal de despido.

### No hay abandono sin intimación previa

Para que se configure la causal de abandono, la ley exige que el trabajador haya sido intimado a reintegrarse a trabajar por medio de un telegrama (u otra forma de notificación), con la advertencia de que si no vuelve será despedido.

### “Tomate unos días, no hay problema”

Esta disposición tiende a evitar que el patrón se aproveche del trabajador y le autorice a faltar, para después acusarlo de abandono de trabajo.

### ¿Me puedo quedar tranquilo?

Muchas veces el trabajador al que por alguna razón no se le permite ingresar a trabajar (por ejemplo porque lo han suspendido y no le llegó la notificación), opta por quedarse parado en la puerta de la empresa, o se resiste a retirarse por temor a que le imputen abandono de trabajo. El trabajador puede en estos casos retirarse (y hacer lo que legalmente corresponda) sin tener que quedarse en el lugar de trabajo.

### El despido con causa ...¡a juicio!

Como ya dijimos el patrón puede despedir sin pedirle permiso ni consultar a nadie, si cree que hay una justa causa de despido. Pero puede ocurrir que el trabajador considere (y tenga buenas razones para ello) que no hay tal justa causa de despido, sea porque:

- *El hecho no existió (no es raro que se inventen causas de despido).*
- *No fue él sino otro el autor del hecho que se le imputa.*
- *Tuvo razones o hay alguna justificación para que no cumpliera sus obligaciones o para obrar como lo hizo.*
- *El hecho no es tan grave como para justificar el despido (esto es muy común, hay muchos patrones que despiden por cualquier cosa).*

### Despido indirecto

No sólo el patrón puede decidir no continuar la relación por culpa del trabajador: también puede pasar al revés, es decir que el que se porte mal o no cumpla sea el patrón. Las situaciones también son infinitas y tienen que revestir gravedad, igual que para el despido.

Para dar algunos ejemplos:

- *Agresión del patrón al empleado.*
- *Falta de pago de remuneraciones.*
- *Rebaja de categoría o traslado que cause perjuicio al trabajador.*
- *No permitirle el ingreso al establecimiento.*

Salvo el caso de agresión al trabajador, en todos los casos en que el empleador no cumple con sus obligaciones es necesario que el trabajador previamente intime al empleador a cumplir con esa obligación (dejarlo entrar a trabajar, pagarle el sueldo, dejar sin efecto el cambio de tareas), advirtiéndole que si no cumple el trabajador se considerará despedido. Las indemnizaciones en este caso serán las mismas que en el caso de despido sin causa (art. 242 LCT)

### El despido indirecto ...¡a juicio!

Naturalmente que casi ningún empleador aceptará haber incurrido en una causal que habilite al trabajador a declarar el despido indirecto. Entonces, al trabajador no le quedará otro remedio que ir a juicio para cobrar su indemnización siempre que pruebe la inconducta o incumplimiento del patrón. Mientras tanto habrá que rebuscárselas para dar de comer a la familia. De ahí que muchos trabajadores aguanten cualquier cosa sin ejercer el derecho a darse por despedidos porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Eso sí: como compensación, de prosperar el reclamo, pueden cobrar el recargo del 50% que fija la ley para los casos en que se no se paga la indemnización.

## **Otras causas de extinción del contrato de trabajo**

### Renuncia

Menos dramático que el despido es el supuesto de extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador. La ley pone condiciones a la renuncia para evitar que el patrón se aproveche del trabajador. Por eso la renuncia no es válida si no se efectúa por telegrama o ante una autoridad del Ministerio de Trabajo. Al tener que concurrir a una oficina de correos o ante la autoridad del trabajo se evita que al empleado le exijan firmar la renuncia sin fecha al momento de ingresar para luego usarla, cuando a la patronal le venga bien, o que le hagan firmar la renuncia bajo presión o engaño.

### Incapacidad absoluta del trabajador

Ya hemos visto al hablar de enfermedades inculpables que el trabajador que, después de haber gozado de la licencia por enfermedad, no logra curarse y queda incapacitado para el trabajo tiene derecho al cobro de una indemnización (art. 212 4to. párrafo LCT). Esa indemnización es equivalente a la indemnización por antigüedad. Esto es un mes por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses y se acumula con la que pudiera corresponderle al trabajador por enfermedad o accidente causados por el trabajo si correspondiera.

### Muerte del trabajador

En caso de producirse la muerte del trabajador vigente el contrato de trabajo, el empleador deberá abonar a sus familiares con derecho a pensión una indemnización equivalente a la mitad de la que corresponde por antigüedad. Esta indemnización se acumula con el seguro de vida obligatorio que debe contratar el empleador, con otros seguros de carácter colectivo que hubiera podido contratar en vida el trabajador, y a las indemnizaciones derivadas de enfermedad o accidente de trabajo si correspondiere. (art. 248 LCT)

### Muerte del empleador



En circunstancias excepcionales, como la muerte del empleador también puede significar la finalización del contrato de trabajo, por ejemplo, la secretaria de un médico, la asistente de un artista. Estas situaciones dan lugar al pago de una indemnización reducida a la mitad.

### Jubilación del trabajador

Finalmente llegamos a la situación del trabajador que no renunció, ni lo despidieron, ni quebró la empresa, ni se incapacitó ni falleció, y llegó al final del recorrido laboral al momento de su jubilación. En estos casos la ley contempla que, en la medida en que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, esto es, haya alcanzado las exigencias de edad y años de aportes como para alcanzar el beneficio, el empleador puede remitirle un telegrama mediante el cual le intima para que inicie los trámites jubilatorios. Al mismo tiempo el patrón deberá entregarle la correspondiente certificación de servicios para que pueda iniciar la gestión de su beneficio. A partir del momento en que el trabajador habiendo sido intimado, recibe la certificación de servicios, tiene un año de plazo para iniciar el trámite. Vencido el año el contrato se extinguirá sin derecho a indemnización alguna (art. 252 LCT).

### **Indemnizaciones y recargos indemnizatorios**

#### Las indemnizaciones básicas:

Hay dos obligaciones básicas del empleador en caso de despido:

- *Preavisar (o pagar la indemnización sustitutiva).*
- *Pagar la indemnización por antigüedad.* Estas obligaciones se devengan en los siguientes casos:
- *Despido sin causa.*
- *Despido con invocación de causa que no resulta acreditada en juicio.*
- *Despido indirecto dispuesto por el trabajador, luego de justificar su causal en un juicio.*

Además de lo que ya hemos visto en cuanto a la obligación de preavisar (o pagar la indemnización sustitutiva) y pagar la indemnización por antigüedad, hay otras indemnizaciones o recargos en las indemnizaciones que se acumulan sobre estas.

#### Indemnización por antigüedad o despido

El sistema de protección contra despidos está basado en una indemnización “*tarifada*”, es decir, una tarifa fija que se presume que repara todos los daños que provoca la decisión de despedir sin que pueda reclamarse más (alegando el trabajador que ha sufrido un daño superior), ni que se quiera pagar menos o nada (en el caso que el patrón alegue que en realidad el trabajador salió ganando porque consiguió un trabajo mejor que aquél del que fue despedido).

#### Cómo se calcula la indemnización por antigüedad

Esta indemnización se calcula en función del tiempo acumulado por el trabajador en la empresa, a razón de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses. En caso de trabajadores que tienen remuneraciones variables (porque están retribuidos a comisión, o porque hacen regularmente horas extras), se toma el sueldo más alto de los últimos doce meses. No se computa ni el aguinaldo ni tampoco los pagos de carácter excepcional, como premios o gratificaciones. Se toma como base el sueldo “bruto” es decir el monto nominal abonado, sin computar las deducciones o retenciones con destino a la seguridad social.

## Pero hay un tope...

Desde 1991, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo estableció un límite al salario que habrá de servir de base para el cálculo de la indemnización. Aunque mantuvo el sistema de un mes por cada año trabajado, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual del trabajador, fijó un límite a esa base de cálculo. Ese límite es el equivalente a tres veces el promedio de sueldos del convenio colectivo aplicable a la relación. El promedio se determina en función de sumar cada una de las remuneraciones fijadas en cada categoría del convenio, y dividir ese importe por la cantidad de categorías. Ese promedio de remuneraciones multiplicado por tres, determina el tope máximo a computar por cada año de antigüedad.

Es así que si un trabajador tiene un sueldo de \$20.000, y el triple del promedio arroja un total de \$15.000 la indemnización se calcula multiplicando esos \$15000 por los años trabajados. La cuestión ahora reviste menos gravedad porque últimamente los sueldos de convenio han ido aumentando, y no es tan frecuente, que alguien gane más de tres veces ese promedio. Pero en ciertos casos (trabajadores remunerados a comisión, viajantes, jerárquicos) la situación puede presentarse.

## ¿Y los que están fuera de convenio?

Para el caso de trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio colectivo de trabajo, la ley prevé que igual se les aplique el tope correspondiente al convenio que se aplica en esa empresa, y en caso de que hubiera varios convenios aplicables en el establecimiento, se aplica el convenio más favorable. El Ministerio de Trabajo es el encargado de fijar los topes que corresponden a cada convenio.

## Declaración de inconstitucionalidad del tope

Este sistema de topes fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2004, ya con la nueva integración del Tribunal. En un fallo que llegó a esa máxima instancia judicial, se estableció que el tope no podía ser menor al 67% del sueldo que percibe el trabajador. En un sueldo de \$100.000, entonces, el tope no puede ser inferior a \$61.000.

## Cómo se calcula la indemnización por falta de preaviso

En los tres casos de despido que hemos visto, además, el empleador tiene que otorgar uno o dos meses de preaviso. El preaviso, cuando no ha sido otorgado genera la obligación de pagar una indemnización que compense el o los sueldos dejados de ganar. El preaviso se cuenta a partir del primer día del mes siguiente al de su notificación. De ahí que si, por ejemplo, la comunicación llega el día 5, el empleador queda obligado a pagar los 25 días que faltan hasta terminar el mes, a título de “integración del mes de despido”.

La indemnización debe ser equivalente al sueldo que hubiera cobrado el trabajador si le hubieran otorgado el preaviso. Si cobra remuneraciones variables se calcula en función del promedio de sueldo de los últimos seis meses o tres meses, según cuál sea más ventajoso para el trabajador.

## Otras indemnizaciones que se calculan de la misma forma

Este cómputo de antigüedad también se utiliza para abonar otras prestaciones que se devengan por otros motivos de extinción del contrato:

- *Es el caso en que el trabajador se retira por incapacidad absoluta.*

En otros casos la indemnización se calcula igual, pero se paga la mitad:

- *Fallecimiento del trabajador.*

- *Incapacidad parcial del trabajador cuando en la empresa no hay tareas adecuadas a sus posibilidades.*
- *Despidos por causas económicas.*

### Hay casos en que no se paga ninguna indemnización

Recordemos que hay situaciones en las que el trabajador cesa su desempeño en la empresa, sin cobrar indemnización:

- *En caso de renuncia.*
- *En los casos de despido con justa causa que el trabajador no logró revertir a través del juicio.*
- *También en los casos en que se consideró despedido, y en el juicio se le rechazaron los motivos para adoptar esa decisión.*
- *En los casos en que el trabajador se retira por jubilación ordinaria.*

### Recargos en la indemnización por despido

Recientemente, como una reacción frente a abusos de las patronales, y reconociendo la insuficiencia de la indemnización por despido en las actuales circunstancias, las leyes han ido estableciendo adicionales y recargos, no sólo respecto de las tarifas del despido, sino también para otros casos en que aún, no habiendo despido, se verifican incumplimientos de parte del empleador.

### Otras obligaciones que se adicionan a la indemnización por despido

Las indemnizaciones, que se adicionan o incrementan la indemnización por despido son las siguientes:

- *Duplicación de las indemnizaciones por despido y preaviso en los casos en que el despido del trabajador se produce luego de haber intimado a la registración del contrato total o parcialmente no registrado (esto ya se ha visto en el capítulo referido a empleo no registrado (art. 15 ley 24.013).*
- *Duplicación de la indemnización por antigüedad en los casos de en qué la relación estuviera mal registrada. Esta indemnización no se acumula con la prevista en el párrafo anterior, pero es más amplia porque se aplica:*
  - *A trabajadores no registrados que no han intimado a la regularización de los contratos.*
  - *A trabajadores registrados con un régimen legal o convencional distinto del que realmente corresponda.*
  - *A todas las situaciones de fraude.*

### Recargo por falta de pago de la indemnización en caso de despido

Es bastante común que las empresas despidan y se niegan a pagar las indemnizaciones, o que incumplan con sus obligaciones provocando que el trabajador se considere despedido. En todos esos casos el trabajador debe iniciar juicio y los empleadores, especulando con la necesidad del trabajador, muchas veces buscan pagar menos o pagar en largas cuotas.

Para intentar prevenir esta situación se ha establecido un recargo del 50% en la indemnización por despido en todos los casos en que el trabajador deba accionar judicialmente para cobrar dicha indemnización. Este recargo se aplica no sólo al caso de despido sin causa en el que la patronal se niega a pagar la respectiva indemnización, sino también en la hipótesis de despido indirecto dispuesto por el trabajador o cuando se invoca una causa de despido que no resulta acreditada. También en los casos en que la indemnización por despido resulta abonada de modo insuficiente respecto de la parte por la que hay que hacer juicio.

## La famosa y hoy desaparecida “doble indemnización”

En la crisis del año 2001 se produjo una verdadera oleada de despidos que se intentó frenar (exitosamente en buena medida) estableciendo un recargo del 100% en las indemnizaciones por despido y preaviso. Esa indemnización fue paulatinamente reducida en la medida en que se fueron recuperando los empleos, y quedó eliminada cuando la tasa de desempleo resultó inferior al 10%.

## Indemnizaciones que se adeudan en cualquier caso de extinción del contrato

La tentación de los patrones por incumplir las obligaciones con el sistema de seguridad social dio lugar a la implementación de nuevas indemnizaciones que buscan castigar este tipo de conductas y fomentar el cumplimiento de esas obligaciones. Es interesante destacar que estas indemnizaciones se devengan no sólo en los casos de ruptura del contrato de trabajo por despido, sino también en cualquier otro supuesto de desvinculación:

- *Renuncia.*
- *Jubilación del trabajador.*
- *Extinción del contrato por invalidez.*

## Sanción por falta de entrega del certificado de trabajo

El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo instituyó una indemnización de 3 meses de sueldo en los casos en que el empleador no entregue la correspondiente certificación de servicios dentro del plazo de treinta días y luego de haber sido intimado por el trabajador. Muchas veces los patrones actúan como agentes de retención de importes que se descuentan del sueldo del trabajador. Además de los descuentos obligatorios (jubilación, obra social, cuota sindical, contribuciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo), también hay otros descuentos que se efectúan a pedido del trabajador y con su conformidad (mutuales, cooperativas, farmacias o proveedurías sindicales). Si el empleador no efectuó los correspondientes depósitos de las sumas descontadas por estos conceptos, luego de ser despedido, el trabajador puede intimar a su empleador para que en el plazo de 30 días demuestre haber depositado esos importes, y si no cumple, la ley prevé una indemnización mensual equivalente al último sueldo cobrado, que se devenga hasta el momento en que el patrón deposite ese dinero. Es como si el despido no se hubiera producido, mes a mes se sigue acumulando el sueldo.

## **Las fallas del sistema de despido con pago de indemnización**

### Antes era otra cosa...

Durante muchos años este sistema de protección contra el despido funcionó eficazmente. Eran tiempos en que había trabajo, y trabajo en blanco y seguro. No como ahora. Entonces un trabajador que resultaba despedido, cobraba la indemnización y al poco tiempo encontraba otro empleo más o menos igual que el que tenía. Muchas veces conseguía el nuevo trabajo antes de gastarse toda la indemnización, que le quedaba como un ahorro.

### Ahora en cambio...

Ahora las cosas han cambiado. El trabajo escasea sobre todo el trabajo en blanco y estable. Entonces un trabajador que es despedido, muy difícilmente consigue otro empleo más o menos igual al que perdió. La indemnización no alcanza a cubrir el daño (inmenso e irreparable en muchos casos) el trabajador se la irá gastando y terminará haciendo changas, o viviendo de la solidaridad de sus allegados. Esto ha dado lugar a un debate sobre la posibilidad de modificar el sistema.

### **Otras formas de protección contra despidos**

#### Estabilidad

En algunos países, o para determinados casos, la ley contempla que el trabajador despedido sin motivo tiene derecho a volver al empleo. En nuestro país, sólo tienen ese régimen legal

- *Los empleados públicos (“estabilidad del empleado público” dice la Constitución).*
- *Los dirigentes y delegados sindicales.*

En otros tiempos tenían este régimen de estabilidad los trabajadores bancarios y de empresas de seguros, aunque hace muchos años que fue suprimido.

#### Propuesta de despido

En otros países rige un sistema que se conoce como de “propuesta de despido”, en el cual, el patrón no puede despedir por su propia voluntad sino que tiene que dirigirse a una autoridad (Ministerio de Trabajo, juez, o un tribunal paritario) para plantear su decisión de despedir a un trabajador. Tiene que explicar los motivos que pueden ser desde faltas graves que hacen imposible continuar la relación laboral u otras relacionadas con su poco cumplimiento capacidad o adaptación al trabajo, supresión del cargo o el sector donde presta servicios, o necesidad de reducir personal. En este sistema el patrón tiene que explicar los motivos para despedir. No puede despedir por su propia decisión.

#### Despido sin causa con pago de indemnización

El régimen legal argentino permite al patrón despedir a su empleado sin dar razones o motivos, y con la obligación de pagar una indemnización. Nada más. Este despido se conoce con el nombre de despido sin causa, no porque no tenga causa (siempre hay un motivo), sino porque el patrón no tiene que explicar esa causa.

#### Enfermedades y accidentes del trabajo

Los accidentes de trabajo y sus consecuencias fueron una de las principales preocupaciones de los trabajadores desde el comienzo de la era industrial. En las condiciones precarias en las que se desenvolvía el trabajo en aquella época, donde además prácticamente no había medidas de protección o prevención de accidentes, la situación de los trabajadores accidentados era particularmente dramática porque quedaban incapacitados para trabajar, sin auxilio alguno de la seguridad social, que por entonces no existía. De ahí que una de las primeras reivindicaciones obreras fuera justamente la referida a la reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo. En esa época se le daba preferencia a la reparación (asistencia médica e indemnizaciones por incapacidad o muerte), más que a la prevención de los accidentes. En nuestro país justamente una de las primeras leyes laborales fue la ley de accidentes de trabajo 9688, de 1915.

#### La Ley de Riesgos del Trabajo 24.557

Como parte de las propuestas para bajar los costos laborales que se conocieron como “*flexibilidad laboral*”, en el año 1995 se dictó una nueva ley llamada Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). El texto original

de la ley 24.557 de la LRT tenía indemnizaciones muy bajas, excluía buena parte de las enfermedades y prohibía al trabajador hacer juicio para mejorar su reparación. Luego de un proceso de varias etapas la lucha de los trabajadores y sus abogados en los Tribunales fueron dando lugar a fallos que desarticulaban buena parte de la ley, y luego a nuevas leyes que mejoraron la situación de los trabajadores.

A continuación expondremos el panorama actual del régimen de la LRT.

### Las ART: el seguro obligatorio

La LRT estableció la obligación para todos los empleadores (con excepción de los que por su capacidad económica pudieran elegir ser *autoasegurados*) de contratar la cobertura de los infortunios de trabajo con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). El propósito original de la ley es el de trasladar toda la responsabilidad a la ART, liberando por completo al empleador. En caso de accidente, todo corre por cuenta de la ART.

Las ART tiene la misión de:

- *Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de sus asegurados.*
- *Pagar los salarios de incapacidad del trabajador durante las ausencias por accidentes o enfermedades reconocidas por la ley.*
- *Brindar la asistencia médica a los trabajadores.*
- *Abonar las indemnizaciones por incapacidad definitiva o por muerte del trabajador.*

### Panorama actual de la ley después de todas las reformas

En este complicado panorama, vamos ahora a desarrollar cómo funciona en la práctica el sistema de cobertura por accidentes o enfermedades del trabajo.

### Infortunios cubiertos

La ley cubre distintas contingencias que pueden afectar al trabajador:

#### El accidente de trabajo

La ley cubre cualquier accidente que el trabajador sufra por el hecho o en ocasión del trabajo. Quedan comprendidos accidentes causados por desperfectos o fallas en máquinas o instalaciones. También los que son consecuencia de errores del propio trabajador o de un compañero de trabajo. Incluye también situaciones de agresión provocadas por terceros.

#### El accidente de trabajo in itinere

La ley también protege el supuesto de accidentes que se producen en el recorrido que debe efectuar el trabajador desde su casa al trabajo y viceversa. Este supuesto se conoce con el nombre de accidente in itinere que es una expresión latina que significa “*en el itinerario*”. ¡¡Atención!! Contra lo que se suele decir, no hay un tiempo límite para que el accidente in itinere sea considerado como tal. Simplemente es el trayecto de ida y vuelta, no importa cuánto tiempo se tarde en llegar (pueden ser cinco minutos para los que viven muy cerca, o varias horas en el caso del que vive lejos).

### Enfermedad profesional

Las enfermedades provocadas por el trabajo también se encuentran protegidas, aunque la LRT intentó limitar la protección solamente a enfermedades que guarden una estrecha relación entre la dolencia

y el trabajo. Es lo que se conoce como enfermedad profesional, y se encuentran en un listado que indica cuáles enfermedades son consideradas profesionales para cada trabajo. De esta manera, al dictarse la LRT, se trató de dejar afuera la mayor cantidad de las enfermedades causadas por el trabajo y que en el régimen legal anterior estaban comprendidas.

### Enfermedades del trabajo que no están en el listado

Aunque la ley no reconoce como enfermedades a las que no están en el listado fijado por la ley, igualmente los trabajadores pueden reclamar ante la justicia, y si se prueba que el trabajo ha sido la causa de la incapacidad, la indemnización procede.

### **Prestaciones**

#### El sistema de reparación de infortunios de trabajo establece determinados derechos en caso de accidente

En primer lugar, una vez ocurrido el infortunio, el trabajador tiene derecho a:

- *Percibir los salarios de incapacidad transitoria durante el tiempo que le lleve recuperarse para volver al trabajo.*
- *Recibir asistencia médica sin cargo.*

Una vez que se ha agotado el tratamiento del trabajador y se le ha otorgado el alta médica (o si de resultas del accidente o enfermedad el trabajador hubiera fallecido) le corresponde una indemnización en dinero para compensar el daño sufrido por el trabajador o su familia.

#### Forma de calcular la indemnización

La indemnización por infortunios del trabajo se fija tomando como base la remuneración mensual del trabajador (calculada a razón del promedio de sueldos cobrado durante todo el año). Ese importe se multiplica por 53, y esos 53 meses de sueldo pasan a ser la base, o punto de partida para calcular la indemnización. El importe se ajusta en función de la edad del trabajador al momento del hecho, aplicando un coeficiente que resulta de dividir 65 por la edad de la víctima. Es decir que si el trabajador tiene 30 años, el coeficiente resulta de  $65 \div 30 = 2,17$  Y si tiene 50 es de 1,30 ( $65 \div 50$ ). De este modo, para un trabajador que percibe una remuneración de \$25.000, y tiene 30 años de edad, la indemnización total (es decir incapacidad absoluta o muerte), será de  $\$25.000 \times 53 \times \text{coeficiente } 2,17$ , total \$ 2.875.250.

Si la incapacidad es parcial (digamos el 20% ) se paga ese porcentaje de la suma total ya mencionada, en este caso \$575.050 Según una reforma reciente (noviembre de 2009), el valor de referencia para determinar las indemnizaciones no puede ser nunca menor a \$180.000. Es decir que si por cualquier causa el cálculo precedente resulta inferior a \$1.234.944 al día de hoy, ese importe será tomado como punto de partida para determinar la indemnización.

#### Las prestaciones adicionales

En los casos de grave incapacidad o muerte, la ley establece el pago de una suma adicional igual para todos, cualquiera sea el sueldo o la edad:

Incapacidad parcial superior al 50% \$ 548.864

Incapacidad total \$ 686.080

Muerte\$ 823.292

Como para compensar esa injusticia de tener que cobrar mediante un juicio, la ley ha instituido un pago único que se suma a las indemnizaciones ya mencionadas, para situaciones de gravedad, que también han sido aumentadas por el decreto de noviembre de 2009: El valor total que resulta de la indemnización, sumada o no la indemnización adicional, tiene a su vez un incremento del 20% por daño extrapatrimonial o daño moral. Así llegamos al total. Estas indemnizaciones se suman, en todos los casos, al importe ya mencionado que, aunque la ley obliga a cobrarlo en cuotas, el trabajador puede pedir (con apoyo en el fallo de la Corte) cobrarlo en un pago único.